

1501627-52.2021.8.26.0123

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Éverton Willian Pona

Comarca: Capão Bonito

Foro: Foro de Capão Bonito

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... instaurada para a apuração da prática de tráfico de entorpecentes.

Presente as condições e não havendo preliminares ou prejudiciais a serem analisado, passo à análise do mérito.

2.1 Sobre o delito de tráfico de entorpecentes

A materialidade da conduta imputada ao réu encontra-se devidamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01-02), ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Capão Bonito

Foro de Capão Bonito

2ª Vara

Rua Rafael Machado, 50, Capão Bonito-SP - cep 18304-130

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501627-52.2021.8.26.0123 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501627-52.2021.8.26.0123

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2146986/2021 - DEL.POL.CAPÃO

BONITO, 18228230 - DEL.POL.CAPÃO BONITO, 954/21/414 - DEL.POL.CAPÃO BONITO, 2146986 - DEL.POL.CAPÃO BONITO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSUE DE ABREU

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Éverton Willian Pona

Vistos.

1 RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública, sob o rito ordinário, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de JOSUÉ DE ABREU, já devidamente qualificado nos autos, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Segundo consta na denúncia (fls. 77-79), no dia 31 de maio de 2021, por volta das 12:30 horas, na Rua Frei Ponciano, altura do nº 490, Vila São Judas Tadeu, nesta

cidade e comarca de Capão Bonito, JOSUÉ trazia consigo, para fins de tráfico, droga consistente em 9 porções de "crack" (cocaína), individualmente embaladas, com massa bruta total de 3,86 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o Ministério Público, JOSUÉ traficava drogas no local acima indicado, próximo a um bar, fato que chegou ao conhecimento da Polícia Civil. Policiais seguiram para lá a fim de averiguar as informações e, durante vigilâncias veladas ("campanas"), visualizaram JOSUÉ entregar, por diversas vezes, alguma coisa a pessoas com características de usuários e, na sequência, recebendo algo em troca, situação típica de tráfico de rua.

Diante do apurado, no dia dos fatos, os agentes policiais retornaram ao local e notaram que JOSUÉ se aproximou portando um botijão de gás, em atitude suspeita, deliberando pela abordagem. Realizada revista pessoal, os policiais encontraram em poder de JOSUÉ as porções de "crack" acima descritas, individualmente embaladas e prontas para a venda, e R\$ 170,00 em cédulas de valores variados e moedas, cuja origem não foi justificada a contento.

Acompanharam os autos deste processo o recebimento da denúncia às fls. 80-82 seguindo-se a regular citação do réu às fls. 110, com posterior apresentação de resposta à acusação (fls. 93-95).

Realizou-se audiência de instrução na qual foram ouvidas as testemunhas e interrogados os réus. Nada foi requerido na fase no art. 402, do Código de Processo Penal.

Em alegações finais o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa pretende a desclassificação para a posse de drogas para uso pessoal.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Passo à fundamentação e decisão.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação penal instaurada para a apuração da prática de tráfico de entorpecentes.

Presente as condições e não havendo preliminares ou prejudiciais a serem analisado, passo à análise do mérito.

2.1 Sobre o delito de tráfico de entorpecentes

A materialidade da conduta imputada ao réu encontra-se devidamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01-02), boletim de ocorrência (fls. 21-24), auto de exibição e apreensão (fls. 25-26), auto de constatação preliminar (fls. 27), laudo pericial de fls. 137-140, positivo para cocaína, e pela prova oral colhida em juízo.

Em relação à autoria, de se considerar que o réu foi preso em flagrante delito, e em solo policial, disse que: nunca foi preso antes, nem processado, apenas realizou transação penal nos termos da lei 9099/95; tem um filho de 08 anos que esta sob os cuidados da mãe; não está machucado; nega comercializar drogas; na data dos fatos, estava indo comprar um gás e parou antes no bar onde foi abordado para tomar um "todinho"; a droga localizada lhe pertence, pois é usuário; o dinheiro é fruto do seu trabalho, pois tem uma quitanda em sua casa onde realiza o comércio; reperguntas da defensora constituída: estava no bar onde foi abordado porque foi comprar um "todinho"; foi abordado por dois policiais; tinha outras pessoas consigo ali e nenhuma foi abordada; é usuário e as drogas dariam para 03 dias. (fl. 06) Interrogado em juízo, disse que: estava com 9 pedras para uso e foi pegar o gás para a genitora; o dinheiro era para a compra do gás e do bar, do qual o depoente é proprietário.

A testemunha, Silvio Almeida de Oliveira, policial civil, ouvido em solo policial, disse que: pertence ao Setor de Inteligência da Seccional de Itapeva; na data dos fatos, estavam checando uma denúncia de tráfico de drogas no bar, palco dos acontecimentos; resolveram fazer campanas com a finalidade de verificar a

procedências das informações; foi possível constatar uma movimentação anormal em tal bar de pessoas que aparentavam ser usuárias de drogas; visualizaram a pessoa posteriormente identificada como sendo JOSUÉ entregando algo para tais pessoas ao passo que recebia dinheiro em troca; estavam de longe e pelo menos por duas vezes viram o acusado entrando e saindo do bar, sempre repetindo as operações com tais pessoas; em virtude desse comportamento suspeito decidiram pela abordagem; esperaram então ele novamente se aproximar do local, sendo que desta vez ele trazia consigo um botijão aparentemente para disfarçar sua real intenção, ou seja, de traficar drogas; assim o fizeram e na ocasião, foram encontradas com ele 09 porções de droga tipo "crack", além de R\$ 170,00 em dinheiro cuja origem não soube explicar; esse montante era composto por várias notas de baixo valor, confirmando, portanto, as denúncias no sentido de que ocorria tráfico pelo local; indagado acerca dos fatos, o acusado apenas negou o comércio, ressaltando ser usuário, fato esse que entendendo não fazer sentido, pois o visualizaram por diversas vezes entregando os objetos que posteriormente confirmarmos se tratar de droga. (fl. 03). Em juízo relatou que: havia denúncias de tráfico no local e dando contato de se tratar de josué; passaram a monitorar o local a distancia; por diversos dias verificaram que pessoas adentraram o bar, usuários de entorpecentes; verificaram que as pessoas pegavam algo da mão dele e entregavam dinheiro a ele e saíam do local; na data dos fatos observaram josué sair do local e ir até a residência em que já tinham conhecimento ser de onde estava pegando os entorpecentes; o réu voltou com um botijão de gás para disfarçar; havia um usuário esperando no bar; resolveram abordar o réu e encontraram as 9 pedras de crack, o botijão e o dinheiro; fizeram campanhas em dias alternados, entre 15 a 20 dias.

A testemunha, Alessandro Corbage de Sá, policial civil, ouvido em solo policial, disse que: pertence à Unidade de Inteligência da Seccional de Itapeva; na data em questão, recebeu denúncia anônima de que no bar localizado no local dos fatos estava ocorrendo tráfico de drogas; juntamente com meu parceiro Sílvio, resolveram realizar campanhas, a fim de checar a veracidade dos fatos; instantes depois visualizaram o acusado JOSUÉ entrando no bar e entregando algo para pessoas que aparentavam ser usuárias de drogas, recebendo alguma coisa em troca, ao que parecia dinheiro; estavam de longe para verificar a denúncia, decidiram chegar mais perto para acompanhar; ressalta que o acusado por umas duas vezes teve esse comportamento suspeito se retirando e voltando do local; resolveram efetuar a abordagem dele, sendo que nessa hora ele voltava com um botijão de gás; na oportunidade da abordagem encontramos com ele 09 porções de droga aparentando ser "crack", bem como aproximadamente o valor de R\$ 170,00 que estavam em notas variadas; acredita que ele estava com o botijão na costa para disfarçar seu real intento, ou seja, traficar pelo local; indagado a respeito disse ser usuário, negando que comercializava no bar; diante dos fatos, apresentaram o acusado nesta unidade para que a autoridade policial deliberasse e tomasse as providências de polícia judiciária. (fl. 05).

Em juízo relatou que: chegou a informação que josué estaria traficando drogas num bar em frente a residência; monitoraram o local por alguns dias e constataram a movimentação típica do tráfico; resolveram abordar o réu no momento da negociação; o réu estava com as 9 pedras, dinheiro em espécie; foram ao local por aproximadamente 2 semanas em dias alternados, em horários diversos; confirma sem sombra de dúvidas se tratar de JOSUÉ o responsável; a denúncia já apontava para JOSUÉ.

No que tange ao depoimento de policiais, ressalta-se não existir dispositivo legal vedando ao agente público servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os milicianos, empossados que são após compromisso de fielmente cumprir em seus deveres, apresentariam testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, têm os funcionários públicos a presunção de que no desempenho de suas atuações agem esmeradamente.

Importante ressaltar que o policial é testemunha como outra qualquer, já que não figura entre os impedidos ou suspeitos, sujeitando-se ao compromisso de dizer apenas a verdade, sob as penas do falso testemunho.

Nessa linha de raciocínio, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que "o valor do

depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

O Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, entende que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal”. (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

No caso sob análise, a atuação dos agentes policiais revestiu-se de legalidade, ao menos pelo que se extrai dos autos, pois não há nenhuma demonstração concreta de irregularidade ou arguição que tenha fundamento a ponto de mudar o quadro formado. Os depoimentos dos policiais foram seguros, coesos e harmônicos entre si, dotados de credibilidade e com força probatória. Nada existe de concreto nos autos a indicar que os policiais ouvidos em juízo estivessem tentando incriminar falsamente o réu, atribuindo-lhe o falso cometimento de um delito.

Do contexto probatório dos autos extrai-se que JOSUÉ negou que as drogas apreendidas se destinavam a comercialização, que eram somente para uso próprio. Contudo, apesar de sua negativa, os policiais afirmaram terem recebido uma denúncia anônima de tráfico no local dos fatos e, ao verificarem, notaram o alto volume de indivíduos que por ali passavam realizando atos típicos dos pontos de traficância de drogas, tanto que ao abordarem o acusado encontraram com ele as porções da droga além da alta quantia em dinheiro agrupado em diversas notas de pequenos valor, também próprio de quem realiza o comércio de entorpecentes.

Veja-se que as testemunhas realizaram campanhas antes da abordagem e constataram a movimentação de JOSUÉ entregando algo rapidamente a usuários, que a seu turno lhe davam algo em troca, e já saíam do estabelecimento. Nessas condições, há provas suficientes de que JOSUÉ realizava a traficância, sendo suficientes para sua responsabilização.

Os réu, de forma consciente e espontânea, trazia consigo, para fins de tráfico, droga, consistente em 9 porções de “crack” (cocaína), individualmente embaladas, com massa bruta total de 3,86 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conduta que se amolda formalmente à previsão abstrata do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Com isso, e esta preenchida a tipicidade formal.

Caracterizada, pois, a tipicidade formal objetiva, imperioso destacar a presença, também, da tipicidade material, ante a efetiva violação do bem jurídico protegido pela norma, bem como, dos elementos subjetivos do tipo. O réu agiu com dolo, nas modalidades cognitiva e volitiva, pois evidente tratar-se de conduta deliberada. O fato é típico, portanto.

Outrossim, não se verificam presentes quaisquer das causas excludentes da antijuridicidade da conduta, previstas no art. 23, do Código Penal. O fato descrito é, assim, típico e ilícito.

Além disso, o réu possui plena capacidade penal e pode ser responsabilizado por seus atos. É penalmente imputável e possui condições de compreender a ilicitude de sua conduta e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Segundo se observa nos autos, possuía conhecimento suficiente, à época dos fatos, para perceber a ilegalidade de sua ação e agir, se assim quisesse de outra forma. Optou pela conduta ilícita quando dele era exigível comportamento diverso. Por tais razões, a sua conduta é culpável.

Desse modo, por se tratar de fato típico, antijurídico e culpável, ausentes quaisquer causas de exclusão da ilicitude, culpabilidade ou de extinção da punibilidade, mostra-se imperiosa a condenação do réu JOSUÉ DE ABREU nas penas do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

2.2 Individualização da pena

Fixadas tais premissas, passa-se à individualização da pena, nos termos do art. 59,

do Código Penal e art. 42, da Lei de Drogas. Adota-se, para a dosimetria da pena, o sistema trifásico previsto no art. 68, do Código Penal.

2.2.1 Dosimetria da pena

Na primeira fase da dosimetria a culpabilidade mostra-se normal e inerente ao delito; não constam antecedentes; não há informações sobre a conduta social ou sobre a personalidade do réu; os motivos são inerentes ao delito, assim como circunstâncias; as consequências são inerentes ao tipo penal; por fim, o comportamento da vítima em nada facilitou para o cometimento da infração. No caso de tráfico de drogas, deverá ser considerado com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (art. 42, da Lei de Drogas). Quanto à natureza, observa-se ter sido apreendida crack. Há maior reprovabilidade quanto a essa circunstância.

Crack, especialmente, apresenta potencial viciante maior, gerando com facilidade a drogadição. Além disso, o crack causa dependência extremamente forte e produz efeito social devastador, facilmente observado nos grandes centros urbanos, que sofrem com a concentração de viciados em referida substância em determinadas regiões, gerando, além de insegurança para a população ao redor de tais conglomerados de viciados, a reiteração de pequenas práticas delitivas praticadas por tais pessoas no intento de sustentar o vício.

Em recente reportagem veiculada em meio de comunicação de credibilidade nacional, afirmou-se que “pequenos municípios do país começam a viver o processo chamado de interiorização do crack. A droga é distribuída a partir das capitais e causa uma série de impactos sociais em locais com menos recursos”, como o caso de Capão Bonito.

Prossegue a reportagem afirmando que o crack “atinge pelo menos 86% dos municípios brasileiros, de acordo com levantamento do Observatório do Crack, criado pela CNM (Confederação Nacional dos Municípios). Segundo os dados da entidade, 4.813 dos 5.568 municípios relataram ter registrado problemas ligados ao crack. Em mais de 20% deles, o nível de gravidade desses problemas é classificado como alto” e reproduz fala da pesquisadora e consultora do Observatório do Crack, Mariana Boff Barreto a qual afirma que “o crack é uma droga de alto poder ofensivo e um combustível para vários tipos de violência” e “Nessas cidades, cresceu muito o número de furtos, roubo, latrocínios, crimes também contra o próprio dependente, ou seja, vários tipos de violência correlacionada”.

Por essas razões, em razão não apenas do seu potencial viciante e destrutivo para a saúde do usuário, mas também pelas consequências sociais que a droga provoca, com aumento da criminalidade, o tráfico do crack deve receber reprimenda maior. Assim, considero negativa a natureza das substâncias.

Em relação à quantidade, foram apreendidos, 9 porções de “crack” (cocaína), individualmente embaladas, com massa bruta total de 3,86 gramas. O montante não se mostra suficiente para ensejar maior reprovação, de modo que a circunstância deve ser considerada positiva.

Em relação ao quantum do aumento nesta fase da dosimetria prevalece na jurisprudência, em razão da ausência de previsão específica na legislação, competir ao magistrado sopesar as especificidades do caso concreto e atribuir o devido valor a cada uma das circunstâncias judiciais. Confirma-se:

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O CP não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 107.860, rel. min. Rosa Weber, 1ª T, DJE de 25-9-2012.).

O STF submete a legalidade da pena ao fundamentado exame judicial das circunstâncias do delito. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação e ponderação dos efeitos da sanção, embasado nas peculiaridades do caso concreto, e no senso de realidade do órgão sentenciante. O art. 59 do CP confere ao juízo sentenciante o poder-dever de estabelecer uma reprimenda apta à

prevenção e simultaneamente à reprovação do delito, sempre atento o magistrado à concretude da causa. Sucede que, em situações como a retratada nos autos, o juiz sentenciante há de considerar parâmetros que são próprios da legislação de drogas. Parâmetros constantes do art. 42 da Lei 11.343/2006. Pelo que o caso é de calibração das balizas do art. 59 do CP com as circunstâncias listadas na pertinente legislação extravagante. No caso, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, diante da natureza e da quantidade de droga apreendida. O que não discrepa da jurisprudência do STF (RHC 108.878, rel. min. Ayres Britto, 2ª T, DJE de 21-11-2011).

Em reflexão sobre a forma de atribuição do quantum atinente a cada circunstância judicial, este magistrado entende, em aperfeiçoamento a posicionamentos anteriores, que a majoração da pena nesta fase da dosimetria em um percentual fixo (1/6 ou 1/8) sobre a pena mínima abstrata prevista na legislação ignora por completo a previsão legislativa acerca do limite máximo da reprimenda estabelecido, tratando de forma igual crimes com gravidade distintas, o que, em última análise, viola o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF).

Isso porque a individualização da pena apresenta-se em três momentos distintos: o legislativo (cominação abstrata da pena), com a fixação dos limites mínimo e máximo da pena; o judicial, com o estabelecimento da pena in concreto; e no momento da execução da pena, quando tem influência o comportamento individual do apenado para a concessão dos benefícios previstos na legislação.

A fase legislativa, de cominação abstrata da pena, representa a reprovabilidade do corpo social em relação à conduta tornada crime. Assim, no momento da aplicação, ignorar que crimes com a mesma pena base podem ostentar penas máximas distintas corresponde a sobrepor-se à reprovação da conduta externada pela sociedade por intermédio dos legisladores.

Desse modo, por serem 10 as circunstâncias constantes no caput do art. 59, do CP, somadas, entende-se que o quantum a ser atribuído a cada uma delas é de, no mínimo, de 1/10 entre a diferença da pena mínima e máxima fixada para o delito. Contudo, forte na jurisprudência, as especificidades do caso autorizam ao magistrado a atribuir maior relevância a uma ou outra circunstância, desde que devidamente fundamentado.

Considerando que no presente caso reconheceram-se duas circunstâncias como negativas (natureza da substância), acresço ao piso 1/10 da diferença entre o mínimo e o máximo abstratamente cominado ao delito e fixo a pena base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, em relação às agravantes e atenuantes, observa-se não constarem quaisquer das situações ou circunstâncias previstas nos arts. 65 e 66, do Código Penal, nem daquelas elencadas nos arts. 61 e 62, do mesmo diploma, razão pela qual mantenho a pena provisória em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa. Por fim, na terceira fase, considerando a primariedade do réu, a ausência de maus antecedentes e ao fato de não integrar organização criminosa, aplico a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Assim, diminuo a pena em 2/3. Portanto, torno definitiva a pena em 2 anos de reclusão e 200 dias-multa.

2.2.2 Regime inicial de cumprimento da pena

Quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, necessário esclarecer que o réu foi condenado pelo delito de tráfico de drogas, o qual é equiparado ao hediondo e, por força do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da determinação por ocasião do julgamento do HC 111.840/ES, em 27/06/2012. Assim sendo, não há vedação à fixação de regime inicial diverso do fechado, mesmo os condenados por tráfico de drogas, consoante o entendimento do STF, por força da necessária individualização da pena, que implica na necessidade de se observarem as circunstâncias do caso concreto e de cada condenado.

Nos termos do art. 59, III, do Código Penal, considerando o requisito objetivo (a

quantidade de pena fixada em 2 anos de Reclusão), o fato de o réu não ser reincidente e tendo em vista as circunstâncias judiciais (art. 33, §3º, do CP), a pena deverá ser cumprida em regime inicialmente aberto.

2.2.3 Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e sursis

No caso o réu foi condenado a pena inferior a 4 anos, satisfazendo o requisito objetivo. Além disso, o condenado não é reincidente e as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal não lhe foram desfavoráveis (ou o crime cometido é culposos). Sua conduta não se mostra incompatível com a vida em sociedade, já que o crime não afrontou a integridade física de outrem, pelo que faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, do CP). Tendo em vista a pena fixada, determino a substituição por duas restritivas de direitos consistente na prestação de serviço à comunidade (art. 44, §2º, do CP), a ser cumprida à razão de 1 hora por dia (art. 46, §3º, do CP), em entidade a ser estabelecida pelo juízo da execução, pelo prazo da condenação e prestação de serviço e a prestação pecuniária no valor de 1 salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

2.2.4 Fixação do valor do dia-multa

Em atendimento ao disposto no art. 49, §1º, do Código Penal, fixo valor do dia-multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, pois não há nos autos informações sobre a condição financeira dos réus.

2.2.5 Detração

A aplicação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal (detração a ser realizada pelo juiz na sentença) carece de uma melhor regulamentação, visto ser dispositivo assemelhado aos regramentos da progressão de regime, matéria pertinente ao juízo das execuções criminais.

Nesse sentido, precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação Criminal – Receptação. Sentença condenatória. Recurso Defensivo pleiteando o reconhecimento da detração para fixar o regime aberto para cumprimento da pena. Materialidade e autoria provadas - Réu surpreendido na condução de veículo produto de furto - Depoimento do policial que merece credibilidade, sendo coeso e harmônico em relação ao conjunto probatório - Confissão judicial do réu que corrobora as demais provas produzidas em juízo - Manutenção da condenação de rigor - Dosimetria das penas - Pena-base fixada no mínimo legal - Manutenção da compensação da circunstância atenuante da confissão com a agravante da reincidência, por ausência de reclamo Ministerial - Entendimento predominante no sentido de que a reincidência prepondera sobre a confissão, nos termos do art. 67, do Código Penal - Vedação da reforma tio in pejus - Penas inalteradas - Regime inicial semiaberto que se mantém em razão da reincidência registrada - Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Detração da pena - questão que deve ser melhor analisada em sede de execução criminal - Recurso improvido. (TJSP; Apelação 0068936-68.2016.8.26.0050; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/08/2017; Data de Registro: 18/08/2017)

Do teor do acórdão extrai-se:

No tocante a aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal, determinando que o tempo da prisão provisória deva ser computado para fixação do regime inicial para o seu cumprimento, entendendo não ser possível sua aplicação, eis que inviável a análise de requisitos subjetivos [...].

No mesmo sentido, recente julgado da 8ª Câmara Criminal do Tribunal Bandeirante, na Apelação nº 016797-87.2012.8.26.048, Relator: Lauro Mens de Melo, donde se extrai que, "inicialmente, inviável entender-se que o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal pode ser considerado como alteração de regime inicial a partir de pena cumprida, funcionando como progressão indireta". Além disso, "trazer para o processo de conhecimento numerosos dados acerca da execução tumultuária o processo, tornaria a prestação jurisdicional confusa e mais demorada, o que certamente vai de encontro aos interesses da defesa".

Com efeito, a progressão do regime por este juízo, em decorrência de custódia cautelar, requer o acesso a dados pessoais do réu, como atestado de comportamento carcerário, a fim de averiguar se possui os requisitos objetivo e subjetivo. Ademais, a detração somente pode ser adequadamente apreciada pelo juízo da execução, que pode analisar todas as condenações do réu e evitar que o mesmo período de custódia cautelar seja utilizado para abatimento das penas em mais de um processo.

Tal análise deve ser feita no âmbito da execução penal, pelo que deixo de realizar a detração.

3 DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu JOSUÉ DE ABREU, pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, às penas de 2 anos de reclusão em regime inicial aberto e ao pagamento de 200 dias-multa.

FIXO valor do dia-multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos.

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por DUAS restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo prazo da condenação e prestação pecuniária no valor de 1 salário-mínimo vigente à época dos fatos.

CONDENO o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais (art. 804, do CPP) e, com base no art. 15, III, da Constituição Federal, enquanto durarem os efeitos da condenação, DETERMINO a suspensão de seus direitos políticos.

4 DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 Prisão preventiva

Conforme a determinação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, DEIXODE DECRETAR a prisão preventiva, pois o réu foi condenado a pena a ser cumprida em regime aberto e a custódia cautelar seria mais rigorosa do que o próprio cumprimento da reprimenda.

O réu poderá recorrer em liberdade.

4.2 Decretação de perdimento dos valores apreendidos

Decreto o perdimento dos valores apreendidos às fls. 09 por ser produto de atividade criminosa

4.3 Determinações finais e comunicações

Comunique-se a condenação ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ) e, com o trânsito em julgado:

a) Intime-se o réu para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias (art. 50, do CP e art. 480, das NSCGJ), bem como das custas judiciais no prazo de 60 dias (art. 480, §1º, das NSCGJ). Infrutífera a intimação ou não efetuado o pagamento da multa no prazo assinalado, extraia-se certidão da sentença nos termos do art. 480-A, das NSCGJ;

b) Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ);

c) Expeça-se de guia de recolhimento definitiva ou oficie-se aditando a guia provisória (art. 472, das NSCGJ) e mandado de prisão;

- d) Determino a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas e ainda não destruídas (art. 72, da Lei nº. 11.343/2006);
- e) Comunique-se a SENAD, para o fim previsto no art. 63, §§ 2º e 4º, da Lei nº. 11.343/2006, remetendo relação dos bens e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, os locais em que se encontram e a entidade ou órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente;
- f) Lance-se o nome do réu no rol dos culpados.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Capão Bonito, 29 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA